

第44問

甲は、駅前のスーパーの駐輪場に駐輪してあったA所有の自転車（以下「本件自転車」という。）に鍵が掛かっていないことに気が付き、これをAに無断で持ち出した。もっとも、甲は自転車で片道5分ほどの距離にある自宅へ忘れ物を取りにいくために本件自転車を使用したにすぎず、使用後は直ちに返す意図であった。

15分後、甲が自宅から忘れ物を取り、本件自転車を元の場所に戻そうとした際に、スーパーから買い物を終えて出てきたAが甲の挙動に気が付き、「何をしているか。」と言いながら甲に近付いてきた。甲は遊ぶ金を持ち合せていないことを思い出し、Aから金を奪おうと考え、所持していた護身用のナイフ（刃体の長さ約8cm、以下「本件ナイフ」という。）を突き付けた上で、「うるさい奴だ。痛い目にあいくなかったら金を出せ。」とAを脅した。Aは、「反抗できないこともないが、抵抗したら危害を加えられかねない。」と畏怖し、素直に財布を差し出した。甲は財布をAから奪いとり、本件自転車には乗らず走って逃げ出した。

甲の行動をすぐ近くで見っていたBが、逃げる甲を追いかけてきたため、甲はBを殺して逃げるしかないと考え、当初財布を奪った現場から200mほど離れた場所でBの喉元に本件ナイフを突き刺した。Bは致命傷を負った結果死亡した。

甲の罪責を論ぜよ。

第1 甲が本件自転車を持ち出した点について

客観的には窃盗罪（235）の構成要件要素を充足しており（本件自転車には鍵が掛けられていないものの、スーパーの駐輪場に駐輪してあることからして、スーパー内にいると思われるAの占有が認められるというべきだろう。）、故意に欠けるところもないが、いわゆる一時使用の事案であるから、不法領得の意思の有無が問題となる（**論点** 不法領得の意思 司H27JH1-2H19-2）。

総合 198 頁 論証 85 頁

不法領得の意思として①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思たる不法領得の意思を要求する判例（大判大4.5.21）の立場に立った場合、本件では主に①が認められるかが問題となる。

裁判例には、自転車の一時使用に窃盗罪を否定したもの（京都地判昭51.12.17）がある。これは、数か月間にわたり、繰り返し被害者宅ガレージから自転車を持ち出し、翌朝は元の場所に返していた行為者が、同様の行為をし、ガレージに戻すまでに予想される時間が、最大限2、3時間であった事案について不法領得の意思を否定したものである。これについては、自転車は、一時使用による価値の損耗・減少やその危険性が小さく、自動車に比して財産的価値が低いことなどが考慮されたものであると指摘されている。

本問でも、甲は、往復15分程度で自転車を返す予定であったのだから、不法領得の意思は否定されると解することができる。

第2 甲がAから財布を奪った点

甲がAから金を奪おうと考え、本件ナイフを突き付け、Aを脅した点について、強盗罪（236Ⅰ）の実行行為に当たることは明らかだろう。

したがって、甲には、少なくとも強盗未遂罪が成立する。

もっとも、Aは、反抗を抑圧されていない。そこで、強盗罪が既遂に達するか否かが問題となる（**論点** 「強取」（236Ⅰ）の意義）。

総合 204 頁 論証 87 頁

この点については、暴行・脅迫→反抗抑圧→財物奪取との間に因果関係がないとして強盗未遂罪が成立するとどまると解するのが論理的である。

一方で、このような事案について、「仮りに……被害者に対しては偶々同人の反抗を抑圧する程度に至らなかったとしても恐喝罪となるものではない。」として、既遂とした判例がある（最判昭24.2.8）。しかし、これには学説上批判が強く、また、この事案では、相手方が反抗を抑圧されなかったと認定されたわけではない。

したがって、強盗罪は、未遂にとどまると解すべきだろう。

なお、大阪地判平4.9.22は、別途恐喝既遂罪が成立するとしており、これと強盗未遂罪は観念的競合の關係に立つと処理している（包括一罪とする処理も考えられるだろう。）。

第3 甲がBを殺害した点

1 甲がBを殺害した点につき、強盗殺人罪（240後段）の成立が考えられる。

なお、殺傷行為の客体は必ずしも、強盗の被害者と一致しなくてもよ

いとされている（最判昭25.12.14、最判昭26.3.27）。

- 2 もっとも、Bの死亡結果は、甲が逃走のためにBを攻撃した結果生じたものであるから、240条の結果は強盜の手段たる暴行・脅迫から生じたものであることが必要か否かが問題となる。いわゆる強盜の機会の問題である（**論点** 強盜致死傷罪における暴行・脅迫と負傷・死亡の関連性  司H20）。

 213 頁  95 頁

この点については、手段説、機会説、密接関連性説（拡張された手段説）等の見解があるところ、判例の立場は明らかではないが、機会説に立つものと評されている（最判昭24.5.28等）。ただし、密接関連性説等とも矛盾しないという指摘もある。

本問では、強盜犯人が逃走の際に追跡者を殺傷するという行為の類型性、場所的近接性等から、強盜の機会に生じた結果であるということが出来る。

- 3 また、甲は殺意を有しているから、故意ある場合の処理も問題となる。

判例は、240条後段で処理するという立場に立っている（最判昭32.8.1）から、これに従って論じればよい。

答案構成

第1 甲が本件自転車を持ち出した点について

1 本件自転車の占有はAにある



Aに対する窃盗罪の成否が問題となる



客観的構成要件該当性、故意（38 I）は問題ない



2 不法領得の意思



権利者排除意思、利用処分意思をもって判断する



3 あてはめ



4 甲には窃盗罪は成立しない

第2 甲がAから財布を奪った点

1 強盗罪の成否



「脅迫」あり



少なくとも、強盗未遂罪は成立



2 強盗既遂罪の成否



因果関係が欠け、不成立



3 恐喝既遂罪は成立

第3 甲がBを殺害した点

1 強盗殺人罪（240後段）の成否



「人」には、強盗の被害者以外の者を含む



2 強盗の機会



密接関連性説



あてはめ



3 殺意ある場合も240条後段を適用する



4 強盗殺人罪成立

第4 罪数

Aに対する強盗未遂罪、恐喝既遂罪、Bに対する強盗殺人罪が成立する。そして、前二者は、観念的競合（54 I 前段）となり、後者とは併合罪（45）となる

第1 甲が本件自転車を持ち出した点について

1 本件自転車には鍵が掛けられていなかったものの、駅前のスーパーの駐輪場に駐輪してあることから、スーパー内にいると思われるAの占有に属していると考えられる。

そのため、本件自転車を使用するという甲の行為は、他人の占有する財物を自己の支配内に移す行為であるといえ、「他人の財物を窃取」(235条)するものである。

したがって、窃盗罪(235条)の構成要件の客観面を充足する。

また、その旨の認識に欠けるところもないから、故意(38条1項)を阻却することもない。

2 もっとも、甲は本件自転車を使用した後、これを返還する意図(一時使用目的)であったことから、窃盗罪の成立は否定されるのではない。窃盗罪の主観的構成要件として不法領得の意思の要否、及びその内容が問題となる。

まず、領得罪の成立に、不法領得の意思の有無を判断する必要がある。かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰的な使用窃盗と窃盗罪との区別、さらに、窃盗罪と毀棄罪との区別が困難になるからである。そして、その内容としては、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用者処分意思)であると解する。

3 本問で、甲は本件自転車を短時間乗車する意思を有している以上、②の意思は認められる。

1

しかし、自転車は自動車等と異なり燃料等を消費するものではなく、短時間の使用によって価値を費消するものではない。また、甲が本件自転車を使用したのは、片道5分ほどの距離にある自宅へ忘れ物をとりにいくためであり、また、実際に甲が本件自転車を使用した時間はわずか15分である。

したがって、甲のこのような意思及び使用態様に鑑みれば、不可罰的な一時使用であり、①の意思が認められない。

よって、甲には不法領得の意思があるといえない。

4 以上から、甲には窃盗罪は成立しない。

第2 甲がAから財布を奪った点

1 甲がAに本件ナイフを突き付けた行為は、刃体の長さ約8cmのナイフという殺傷力の高い凶器によって人を脅すものである。これは、社会通念上、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の「脅迫」(236条1項)であるといえるので、甲には強盗罪の「実行」の「着手」(43条本文)がある。

したがって、少なくとも、甲には強盗未遂罪が成立する。

2 そうだとしても、Aは、「反抗できないこともない」と考えており、Aの反抗を抑圧するに至っていない。

強盗罪は被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段とし、財物を奪取する財産罪であるから、暴行・脅迫、被害者の反抗抑圧及び財物奪取全てに因果関係が必要である。そうだとすれば、暴行・脅迫を加えたが被害者が反抗を抑圧されずに財物を交付した場合には、強

2

盗罪は未遂にとどまる（243条）と解すべきである。判例には、このような場合に既遂としたと解されるものがあるが失当である。

3 以上から、甲には、Aに対する強盗未遂罪が成立するにとどまる。

また、客観的には恐喝罪（249条1項）の構成要件を実現しているといえるから、恐喝既遂罪も成立する。

第3 甲がBを殺害した点

1 甲がBを本件ナイフで刺して殺害した点につき、「強盗が、人を……死亡させた」ものとして、強盗殺人罪（240条後段）の成立が考えられる。なお、同条は、強盗犯人が強盗の機会に人を殺傷することが多いことから、生命・身体の安全を保護するために、強盗罪の加重類型として設けられたものであるから、「人」を強盗の被害者に限定する必要はない。そのため、Bに対しても強盗殺人罪は成立し得る。

2(1) もっとも、Bの死亡結果は、甲が逃走のためにBを攻撃した結果生じたものである。そこで、240条（後段）の結果は強盗の手段たる暴行・脅迫から生じたものであることが必要か。条文上明らかでなく問題となる。

同条は強盗の機会に致死傷という残虐な結果が生じることが刑事学的に顕著であるので、生命・身体という法益をも考慮した強盗罪の加重類型である。そうだとすれば、致死傷の結果は強盗の手段である暴行・脅迫から直接生じたことを要せず、強盗の機会に生じたものであれば足りると解すべきである。

ただ、処罰範囲の不当な拡大を防ぐため、財物の奪取・逮捕の妨

3

害・証拠の隠滅等、強盗行為と通常密接な関連性を有する行為により生じた結果に限ると解する。

(2) 本問において、甲の殺害行為は、Bの追跡が継続した状態で、強盗の現場から200m離れた地点で行われており、場所的な近接性が認められる。そして、このような甲の行為は、財布の返還を免れ、逃亡を完遂させるために、強盗犯人たる甲がBに攻撃したことにより生じたものである。強盗犯人が逃亡時に追跡者に対して殺傷行為をなすことはままあるといえる。

以上から、強盗行為と通常密接な関連性を有する行為により生じたものといえる。

3 また、甲には殺意があるが、このような場合には、240条後段のみを適用すべきであると解する。なぜなら、強盗犯人が死亡について故意を有する場合は刑事学上顕著であること、また、結果的加重犯について通常用いられる「よって」の文言が使われていないことから、同条項は故意ある場合を含むと解されるからである。

4 したがって、甲には「強盗が、人を……死亡させた」ものとして、Bに対する強盗殺人罪が成立する。

第4 罪数

以上より、甲につき、Aに対する強盗未遂罪、恐喝既遂罪、Bに対する強盗殺人罪が成立する。そして、前二者は、1個の行為で行われているから観念的競合（54条1項前段）となり、後者とは併合罪（45条）となる。

以上

4